

1500359-41.2022.8.26.0312

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HERCULANO DE SOUSA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

THALIA HERCULANO DE SOUSA, MANOEL FELIPE BATISTA CIRILO e LUCAS HERCULANO DE SOUSA, qualificado nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500359-41.2022.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500359-41.2022.8.26.0312

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HERCULANO DE SOUSA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

THALIA HERCULANO DE SOUSA, MANOEL FELIPE BATISTA CIRILO e LUCAS HERCULANO DE SOUSA, qualificado nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo o artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput do Código Penal, tudo na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal, porque, em tese, no dia 15 de setembro de 2022, por volta de 06h10min, na Rua Gilmara Aparecida Cavalcante de Lima, 86, Cohab Maria de Lourdes Segal, nesta cidade e comarca de Juquiá, agindo mediante concurso, guardavam, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, 27 porções de maconha, com peso aproximado de 63,98g, 73 cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso aproximado de 74,02g, e 136 pedras de crack, com peso aproximado de 40,47g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também que, desde data incerta, mas até o dia 15 de setembro de 2022, na Rua Gilmara Aparecida Cavalcante de Lima, n.º 86 e 115, Cohab Maria de Lourdes Segal,

nesta cidade e comarca de Juquiá, LUCAS HERCULANO DE SOUSA, MANOEL FELIPE BATISTA CIRILO e THALIA HERCULANO DE SOUSA, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, por fim, que desde data incerta, mas certamente entre os dias 1º de setembro de 2022 até 15 de setembro de 2022, nas mesmas circunstâncias de local acima citadas, LUCAS HERCULANO DE SOUSA, MANOEL FELIPE BATISTA CIRILO e THALIA HERCULANO DE SOUSA receberam, em proveito próprio, uma bateria estacionária pertencente a Leandro Tobias Sanches, que sabiam ser produto de crime (RDO nº 4437-1/2022, fls. 127/128).

Os réus foram autuados em flagrante delito. Lucas e Thalia obtiveram liberdade provisória; Manoel teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 78/82).

Recebida a denúncia (fls. 152/155), os acusados foram regularmente citados (fls. 226, 228 e 230) e apresentaram resposta à acusação (fls. 213/220).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de três testemunhas comuns e os réus foram interrogados.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a fixação de penas no mínimo.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas, nem prejudiciais de mérito. Não se vislumbra nulidades, tampouco hipótese de prescrição.

Passo, então, a apreciar o mérito.

A pretensão acusatória comporta parcial acolhimento, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos delitos de tráfico de drogas e receptação, que se configuraram consumados. É clara a tipicidade e não há dúvidas quanto à autoria em relação ao réu LUCAS HERCULANO DE SOUSA. Está correta a classificação dada à conduta.

Em relação aos demais réus, o caso é de absolvição. Consequentemente, também é o caso de se afastar o delito de associação para o tráfico, tudo conforme se verá a seguir.

Eis a síntese da prova oral produzida.

O policial MILTON RODRIGUES MENDES relatou em Juízo que foram cumprir mandado judicial e encontraram as drogas na casa. As drogas estavam em uma sapateira, em uma sacola plástica, embaladas individualmente. O Lucas é que deu a informação da localização das drogas. Pelo que se recorda, ele não disse que as drogas eram para tráfico. Quanto à bateria, ele informou que um indivíduo foi adquirir entorpecentes com ele e ele "segurou" a bateria. Não os conhecia. Ficou um tempo afastado de suas atividades. Eles não estavam sob efeito de drogas e não havia apetrechos para o uso no local. O mandado de busca foi apresentado para eles. Há filmagens da venda do entorpecente, não sabe dizer por parte de qual dos réus. Era noite.

O policial MAURILENO MARTINS PIAUHLINO descreveu em Juízo que tinham recebido de que uma pessoa de nome "piu" estaria comercializando drogas na rua Gilmar Cavalcante. Fizeram campanha e em filmagens conseguiram identificar a venda e o vendedor como sendo a pessoa de nome Lucas. Obtiveram mandado de busca e apreensão. Dentro da residência, identificaram o Lucas, a Thalia e o Manoel. No quarto onde dormia o Lucas observaram uma porção de drogas, todas embaladas. Quem assumiu a propriedade das drogas foi o Lucas. Identificaram a Thalia e o Manoel de outros fatos, então deduziram que eram todos eles que participavam da venda. Tem conhecimento de que a Thalia, quando era adolescente, tinha se associado a uma outra adolescente de nome Denise. O Manoel também, que é companheiro da Thalia. E o Lucas também. Não houve apreensão de apetrechos para uso, apenas droga e dinheiro. O mandado de busca e apreensão foi apresentado. Na residência estava também uma senhora e uma criança de colo. Em algumas filmagens, a Thalia aparece na frente da residência e aparenta estar vendendo a droga também.

A testemunha RENATO afirmou que conhece os réus. Disse que o Manoel ganha a vida trabalhando. Trabalha junto com ele e com o pai dele cortando palmito. Não conhece muito o Lucas. Sabe que a Thalia é mulher do Manoel.

A informante ELIANE disse que estava dormindo e a polícia chegou e invadiu lá.

Levou os meninos. A polícia disse que entrou lá por causa de tráfico. Veio para Juquiá há pouco tempo. Eles já tem passagem. Sabe que o Lucas estava vendendo droga porque estava devendo. O Manoel e a Thalia não estavam vendendo. Descobriu que o Lucas estava vendendo porque ia bastante gente procurá-lo na casa e também porque a polícia foi lá. Não viu a Thalia participando da venda.

A informante AUGUSTA é avó do Manoel e da Thalia e proprietária da casa onde as drogas foram apreendidas. Estava dormindo no dia em que a polícia foi na casa. A testemunha LEANDRO TOBIAS SANCHES, vítima do crime de furto antecedente, narrou em Juízo que foi vítima de furto e a polícia civil recuperou sua bateria. Seu caminhão estava parado na porta da sua casa, por volta das 7h47min, período da manhã, quando um rapaz chegou lá e retirou a bateria. Após, chegou um carro e a bateria foi colocada nele. A bateria tem número de série e nota fiscal, tem certeza que é a sua bateria que foi encontrada com os réus. Não viu quem furtou a bateria. Os policiais não disseram como foi recuperada a bateria. Não conhece os réus. O réu MANOEL FELIPE BATISTA CIRILO, ouvido em Juízo, reconheceu que foi condenado quando era adolescente por posse de droga para consumo e também por tráfico. Nunca atuou em biqueira. Era enquadrado toda hora pelos policiais, mas nunca pegaram nada consigo. Não usa drogas. Ficou queimado por suas passagens. Estava se reconciliando com a Thalia e ia uma ou duas vezes por semana na casa dela. O Lucas ficava na casa sempre com o quarto fechado, ele tinha vindo para Juquiá havia pouco tempo. Os policiais não pegaram nada em seu quarto. Fizeram a varredura no quarto que ficava com a Thalia e seu filho. Pegaram drogas apenas no quarto do Lucas. Nem sabia da bateria. O Lucas informou que havia droga na sapateira e embaixo do travesseiro. Se soubesse que ele estava com drogas nem tinha ido para a casa da Thalia. Não sabia que o Lucas estava vendendo drogas, apenas suspeitava. Não sabe se a Thalia sabia, pois estava se reconciliando com ela. Nunca usou drogas.

A ré THALIA HERCULANO DE SOUSA, ouvida em Juízo, narrou que estava morando junto com seu namorado Manoel, mas tinham brigado e voltou a morar na residência do seu irmão. As drogas eram do seu irmão Lucas. Não sabia que ele estava vendendo, mas desconfiava porque ele ficava muito na rua e por causa do dinheiro. Não sabia da existência da bateria. Sabe que já houve apreensão de droga na casa do seu namorado. Via uma movimentação estranha na frente de casa e desconfiava do tráfico. Isso durou cerca de uma semana. Antes o seu irmão trabalhava como servente de pedreiro.

O réu LUCAS HERCULANO DE SOUZA, ouvido em Juízo, disse que a droga era toda sua. Seu cunhado não tem nada a ver, nem sua irmã. Estava passando necessidade. Estava havia pouco tempo em Juquiá. Disse que os policiais chegaram na casa apontando armas, levantou assustado, o policial falou para não reagir se não ia atirar. Os demais réus não sabiam que estava vendendo drogas. Sua irmã desconfiava, mas não sabia. Em relação à bateria, um cara falou que estava com a carreta parada na estrada e foi comprar drogas, perguntou se queria segurar a bateria. Ele falou que pegaria no dia seguinte. O cara nunca mais foi buscar, por isso ficou lá. Estava traficando havia pouco tempo. Não conhece a pessoa que lhe fornecia a droga. Foi falar com ele uma vez, explicou sua situação de necessidade para ele. Não o conhecia, mas viu que ele vendia drogas por causa do movimento. Pegou a bateria cerca de uma semana antes. Não vendia na casa, vendia na rua. As drogas que estavam na sua casa iam ser vendidas durante o dia. Pegou mais drogas com o traficante umas três vezes. Sabia que o Manoel já tinha tido envolvimento com o tráfico, mas ele já tinha parado desde que saiu da "febem". Soube que sua irmã Thalia estava cumprindo medida de liberdade assistida. O Manoel estava trabalhando com o pai, mexendo com palmito.

A negativa apresentada por Manoel e Thalia não é infirmada pelo restante da prova produzida. Na realidade, nenhuma conduta específica foi apurada em relação aos dois réus, exceto o fato de estarem no lugar em que foram encontradas as drogas no momento da diligência policial.

Fato é, contudo, que o mandado de busca e apreensão foi expedido por força de indícios da prática de tráfico de drogas exclusivamente pelo réu Lucas, tanto que Manoel e Thalia sequer foram mencionados pela representação da Autoridade Policial nos autos nº 1500354-19.2022.8.26.0312.

Naqueles autos, as denúncias que chegaram à Autoridade Policial diziam respeito exclusivamente à pessoa de Lucas, o que se coaduna, ademais, com a prova oral produzida em juízo. Lucas confessou a prática do delito e assumiu a propriedade da droga, isentando Manoel e Thalia de qualquer participação nos fatos.

Nenhuma conduta de Manoel e Thalia foi presenciada, seja por populares denunciantes, seja pelos próprios policiais ouvidos em juízo.

A droga, note-se, foi encontrada apenas no cômodo ocupado por Lucas, que foi também o responsável por indicar a localização das drogas aos policiais que cumpriam o mandado de busca e apreensão.

O prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 - e-book).

Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

O caso, portanto, é de absolvição em relação a Manoel e Thalia.

Com isso, não há que se falar em delito de associação para o tráfico porque a improcedência da ação penal em relação a Manoel e Thalia demonstra igualmente a inexistência de qualquer vínculo associativo entre eles e o réu Lucas. Nesse ponto, não há qualquer prova da existência de associação perene e estável entre os réus, já que nenhuma conduta específica a cargo de Manoel e Thalia foi comprovada. Em relação a Lucas, por outro lado, o caso é de procedência em relação aos delitos de tráfico de drogas e receptação.

A confissão de Lucas, prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não destoa do restante da prova produzida, que demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Bem demonstrado, assim que durante operação deflagrada pela Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido nos autos do processo nº 1500354- 19.2022.8.26.0312, os policiais dirigiram-se até o imóvel localizado na Rua Gilmar Aparecida de Lima, nº 86, no Conjunto Habitacional Maria de Lourdes Segal. No interior da residência, encontraram os denunciados. Durante a vistoria do imóvel, os policiais localizaram em um dos dormitórios, em local indicado pelo réu Lucas, dentro de uma sapateira, uma sacola contendo diversas porções de maconha, crack e cocaína, embaladas individualmente de forma a facilitar a sua comercialização, além da quantia de R\$ 315,90 em dinheiro, em notas fracionadas e diversas moedas.

Ademais, a movimentação de mercancia da droga por parte do réu Lucas já havia sido presenciada pelos policiais civis em data anterior, o que corrobora a destinação da droga ao comércio, o que aliás foi confirmado pelo próprio réu.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 21/22 e nas fotografias de fls. 25/27, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 13/14 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 205/209, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (40,47 gramas de crack, 74,02 gramas de cocaína e 63,98 gramas de maconha), a variedade (cocaína, maconha, crack) e o modo de disposição das drogas (73 envelopes de cocaína, 136 pequenas porções de crack e 27 de maconha) e as circunstâncias em que apreendidas, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido (R\$ 315,90 em notas de 50, 20, 10, 5 e 2, além de moedas diversas).

Quanto ao delito de receptação, tipificado no art. 180, caput, Código Penal, consiste o crime em "adquirir; receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Vê-se que o tipo pressupõe a existência de crime anterior, do qual provém o objeto material, não se exigindo, todavia, a instauração de inquérito policial, ação penal e muito menos de sentença que ateste a ocorrência do delito antecedente, mas apenas sua comprovação nos autos.

In casu, diante da palavra da vítima, dando conta da subtração, e dos demais elementos angariados, a saber, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, fotografias de fls. 23, boletim de ocorrência de fls. 127/128 e auto de entrega de fls. 126, não restam dúvidas de que a bateria estacionaria foi objeto de delito patrimonial antecedente e encontrado na posse do acusado Lucas.

Vale lembrar que o dolo se traduz na consciência e na vontade do agente de realizar os requisitos objetivos do preceito incriminador que conduzem à produção de um resultado jurídico relevante, que lhe era desejado ou, pelo menos, esperado como possível e assumido (art. 18, inciso I, do Código Penal).

Por outro lado, a presença dos requisitos do dolo, direto ou eventual, não pode ser extraída da mente do agente e nem sempre se terá prova direta, cabendo ao julgador a identificação de elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado.

Cabe ressaltar que o STJ já se decidiu sobre o tema:

"[...] Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do recorrido.[...] Agravo a que se nega provimento."

STJ, AgRg no REsp nº 908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva [Desembargadora convocada do TJ/MG], Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008).

Conforme firme entendimento jurisprudencial, a posse da res, com a falta de explicação plausível para tanto, gera forte presunção de responsabilidade.

Caso o réu seja encontrado nessa condição, fato que efetivamente constitui prova forte, incumbe-lhe a apresentação de justificativa plausível, suficiente para afastar a autoria e/ou demonstrar que a sua aquisição deu-se de forma lícita ou diversa daquela estampada na denúncia.

No caso vertente, a autoria e elemento subjetivo do tipo (dolo) são certos.

Isso porque a prova obtida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma a hipótese acusatória e evidencia que o réu recebeu a bateria estacionaria furtada como pagamento pelos entorpecentes comercializados, o que foi reconhecido pelo acusado.

O conjunto probatório é seguro e convincente, formado pelos relatos coincidentes das testemunhas, pela confissão do acusado Lucas e pelos laudos produzidos, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As testemunhas também dão respaldo à hipótese acusatória.

É certo que o depoimento de policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 - e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485.543 – SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem os fatos quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, não se vislumbrando motivo para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu. A condenação do acusado Lucas é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 180, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, preponderantes a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da razoável quantidade apreendida e da diversidade de substâncias. Em relação ao delito de receptação, fixo a pena no mínimo legal de um ano e 10 dias-multa, porque as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não recomendam incremento nesta fase.

Presente a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, utilizada a confissão para a formação do convencimento do julgador, devolvo a pena do delito de tráfico ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – Súmula 545 do STJ.

A causa de diminuição prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas incide em grau máximo, frente à primariedade do acusado, demonstrada pela certidão de fls. 74, e à ausência de notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, além da repercussão da conduta, aparentemente isolada, ser ínsita ao tipo penal. Vão as penas, pois, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em definitivo, nada mais havendo a considerar.

Note-se que considerações acerca da quantidade ou variedade das drogas já foram apreciadas na primeira fase e não influenciam a fração do redutor, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido:

“(…) é preciso se atentar ao fato de que a natureza diversificada dos entorpecentes e a grande quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias que podem ser utilizadas para fundamentar a exasperação da pena-base (LD, art. 42) ou podem servir para a escolha da fração de redução de pena a ser efetivada (LD, art. 33, § 4º). Sob pena de incorrer em bis in idem, não pode o magistrado considerar essas circunstâncias na primeira e, simultaneamente, na terceira fase do processo de dosimetria da pena. A natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração (alternativamente) em uma das fases (primeira ou terceira) da dosimetria da pena, sendo vedada sua valoração cumulativa” (MASSON, Cleber, . Lei de Drogas - Aspectos Penais e Processuais. Grupo GEN, 2021 – e-book).

É esse, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“No julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Tribunal [Pleno], por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada

para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)” (STF: HC 181.841 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 29.05.2020. E ainda: RHC 182.953 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 29.05.2020).

Em relação ao delito de receptação, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Presente o concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), somam-se as penas, que perfazem o total de 2 anos e 8 meses de reclusão e 176 dias-multa. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, à vista do quantum fixado, nada autorizando a fixação de regime mais gravoso, que não pode decorrer de considerações acerca da gravidade abstrata do delito.

A propósito, é esse teor da Súmula 718 do Eg. STF: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.

Considerando, ainda, a primariedade, bem ainda circunstâncias que envolveram o fato, entendo presentes os requisitos e substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução, e outros dez dias-multa. Se necessário o cumprimento, fixo o regime aberto, compatível com esta substituição.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, THALIA HERCULANO DE SOUSA e MANOEL FELIPE BATISTA CIRILO da imputação do cometimento dos crimes descritos na denúncia.

Ainda, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu LUCAS HERCULANO DE SOUSA por infração ao artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ao artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 176 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, à razão de uma hora por dia de condenação, conforme dispuser o Juízo de execução, e mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Dada a solução de mérito adotada em relação a Manoel Felipe Batista Cirilo, REVOGO a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Autorizo a destruição das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado:

a) com relação à pena de multa, nos termos do artigo 480 das NSCGJ (com redação dada pelo Provimento CG nº 05/2022), elabore-se o cálculo e expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público;

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido e depositado nos autos ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União;

d) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição;

e) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

f) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da

gratuidade de justiça que defiro nesta oportunidade, ante a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, reforçada pelo que se apurou na instrução processual.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º)

Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 5 de dezembro de 2022.